

1526861-12.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526861-12.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526861-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2300578/2021 - 26º D.P. SACOMA, 21203377 - 26º D.P. SACOMA, 4109/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2300578 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON VENÂNCIO DA CONCEIÇÃO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

CLAYTON VENANCIO DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 10h50, no interior do estacionamento situado na Rua Serafina Giancoli Vicentini, nº 10, Jabaquara, São Paulo - SP, juntamente com indivíduo não identificado, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra o funcionário A. C. d. S., o veículo Jeep/ Renegade, placas ENU-5318, São Bernardo do Campo - SP, ano/modelo 2019/2020, cor preta, pertencente a R. V. d. P, bem como o veículo VW/Fox, placas FSJ7279, São Bernardo do Campo - SP, ano/modelo 2014, cor

prata, pertencente a R. E. d. C.

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 92/96). O réu foi citado (fls. 146) e apresentou resposta à acusação (fls. 149).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, mas com o afastamento da agravante da calamidade pública e fixação do regime fechado.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao roubo.

Subsidiariamente, postulou a manutenção das penas no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma e a fixação de regime de acordo com o montante de pena

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal é procedente.

A vítima A. declarou que estava trabalhando no estacionamento, quando ali entraram dois indivíduos, um na sequência do outro, sendo que o primeiro trazia um balde, dentro do qual tirou uma pistola que pareceu ao depoente ser um de calibre .765 de cor preta. Tal indivíduo questionou onde estavam as chaves de dois carros, um Renegade e um Fox. O depoente indicou o armário de chaves, ele foi até lá e pegou as chaves dos dois veículos, arremessando as chaves do Renegade para o segundo indivíduo que havia entrado, que entrou no carro e saiu na condução dele. O primeiro indivíduo saiu na condução do Fox. Acionou o 190 e uma viatura que passava pelo local logo após o crime. Cerca de 40 minutos depois o depoente soube da localização do veículo e foi ao Distrito Policial, onde realizou reconhecimento pessoal, oportunidade na qual lhe foram exibidos dois indivíduos, sendo o depoente reconheceu o indivíduo que saiu com o Renegade com absoluta certeza, informando que ele ainda trajava as mesmas roupas do momento do roubo. Na presente data, inicialmente afirmou ter ficado em dúvida entre reconhecer o réu e um terceiro indivíduo, mas depois acabou indicando este como um dos roubadores.

A vítima R. V. d. P. afirmou que é proprietário do veículo Renegade e não presenciou os fatos. Deixou seu veículo estacionado em um estacionamento perto do metrô Jabaquara e soube da subtração apenas por meio de contato do delegado.

Recuperou o veículo sem danos.

A vítima R. E. d. C. afirmou que seu veículo Fox estava em poder de sua esposa, que o estacionou em um estacionamento perto do metrô Jabaquara, como de costume. Soube do roubo por meio de contato de um funcionário do estacionamento. O veículo foi recuperado no mesmo dia. Apenas uma mochila e os óculos escuros de sua esposa não foram recuperados

Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM sobre um roubo de dois veículo ocorrido há pouco, sendo que foram passadas as informações do carro e as características dos indivíduos, sendo um deles com camiseta preta, calça jeans e tênis Mizuno. Pouco depois da irradiação avistaram o veículo Renegade, em local próximo do roubo. Deram ordem de parada, que foi desobedecida, tendo havido acompanhamento até que o veículo foi abordado. Nele estava o réu apenas. Com ele nada de ilícito foi encontrado. Questionado, não soube explicar a origem do veículo. Posteriormente, acabou confessando a prática delitiva, mas não forneceu qualquer dado identificador do outro indivíduo. O réu estava trajado com as mesmas roupas que a irradiação havia descrito.

O réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Assim, há prova suficiente quanto à autoria delitiva em desfavor do réu, a despeito de não ter sido reconhecido em Juízo pela vítima que presenciou os fatos. Ora, o réu foi abordado em poder de um dos veículos subtraídos logo após o roubo e em local próximo do local do roubo. Ele estava com as mesmas vestimentas que foram irradiadas pelo COPOM e a vítima narrou que ao proceder ao reconhecimento no Distrito Policial reconheceu-o, naquele dia, sem qualquer hesitação, esclarecendo que ele trajava as mesmas roupas do momento do roubo, conforme relatado pelos policiais militares. Ao ofendido foram apresentados dois indivíduos naquela

ocasião. Anote-se, ainda, que o réu veio a confessar aos milicianos, informalmente, a prática delitativa. A conjugação de tais fatos permite o acolhimento da pretensão punitiva estatal, portanto.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista tratar-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade.” (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES)

E os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

No mais, o réu não apresentou qualquer versão em Juízo para explicar a posse do veículo em lapso temporal e territorial tão exíguo em relação ao crime.

Com efeito, o concurso de agentes restou devidamente demonstrado pelos depoimentos de A., funcionário do estacionamento, que narrou detalhadamente a dinâmica fática e as condutas dos roubadores, restando inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas, existindo o vínculo psicológico entre os roubadores.

Ademais, o emprego de arma de fogo restou devidamente demonstrado, já que A. foi claro quanto ao fato de que a abordagem ocorreu com uma arma de fogo, que se encontrava nas mãos do comparsa do réu, restando inegável a sua utilização e o

pleno conhecimento de tal circunstância pelo réu, que permanecia dando guarida no momento da abordagem. Vale destacar ser desnecessária a apreensão desta para a incidência da causa de aumento de pena. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 2. No caso, embora a arma não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).

Trata-se de hipótese de concurso formal, vez que no mesmo roubo, o réu e o comparsa atentaram contra o patrimônio de vítimas distintas.

Quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Por fim, observo que os fatos ocorreram após o advento da Lei nº 13.654/18, que passou a prever o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena em parágrafo destacado das demais causas de aumento de pena, com índice superior de majoração. Com tal alteração legal e havendo a incidência de causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos, como ocorre no presente caso, é o caso de aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com incidência apenas da causa que mais aumenta (no caso, o emprego de arma de fogo). A outra causa (concurso de agentes) será considerada como circunstâncias judicial na primeira fase da dosimetria, na medida em que torna a circunstância do crime mais grave, já que o concurso de agentes não apenas facilita o cometimento do delito, como também inviabiliza qualquer capacidade de reação da vítima, dando maior garantia de impunidade e segurança na fuga.

Desta forma, força-se a condenação do réu nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, nos termos acima referido, considerando-se a atuação em concurso de agentes, além dos seus péssimos antecedentes criminais (2ª VC Santo Amaro 0005059-5.2002.8.26.0002 – fls. 159 e 175/ 29ª VC 0050265-85.2002.8.26.0050 – fls. 159 e 175/ e 6ª VC 0086323-14.2007.8.26.0050 – fls. 159/160 e 175, sendo que as penas foram extintas pelo cumprimento em 02/08/2016), razão pela qual suas penas serão elevadas em 1/5, ficando estabelecidas em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Anoto que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, uma vez que o E. STF é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Anoto que o entendimento pessoal desta magistrada é no sentido de que condenação por porte de drogas para uso próprio tem o condão de gerar reincidência ou mau antecedente, pois não houve abolitio criminis, mas mera ausência de estipulação de pena privativa de liberdade, o que não exclui o caráter ilícito da conduta. No entanto, após diversas reformas das sentenças proferidas e observando-se o entendimento mais recente do E. STJ, no sentido de que tal tipo de condenação não gera reincidência ou mau antecedente, curvo-me a tal entendimento. Por isso, a condenação nos autos 2795/2004 (fls. 165 e 176) não será considerada para fins de fixação de pena. Neste sentido:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. EFEITOS AFASTADOS. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, "as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade" (HC n. 453.437/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). 2. No caso, não obstante os esforços do Parquet, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto aplicado o entendimento acima referido, afastando-se os efeitos da reincidência do paciente, não há, portanto, que se falar em reforma ou reconsideração da decisão agravada. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 505536 / SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, j. 19/09/2019).

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, as penas devem ser mantidas no patamar fixado acima.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, as penas devem ser elevadas em 2/3, ficando estabelecidas em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

De rigor a aplicação do concurso formal, como visto anteriormente, razão pela qual as penas devem ser elevadas na fração de 1/6, tornando-se definitivas em 09 (noive) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

A despeito da primariedade técnica do réu, entende-se que o regime inicial de cumprimento de pena deva ser o fechado. Com efeito, deve-se ter em conta a quantidade pena e seus maus antecedentes, o cometimento do delito com o emprego de uma arma de fogo e em concurso de agentes, que recomendam a adoção de tal regime prisional, eis que tal circunstância demonstram maior periculosidade por parte do agente, que se utiliza de artifício que vai além da conduta simplesmente prevista pelo legislador, visando à garantia da empreitada criminosa, o que importa, também, maior risco para a vítima, além de sua clara indiferença aos fins da pena.

O crime tratado nos autos é de suma gravidade, daqueles que mais desassossegam trazem aos cidadãos de bem desta cidade, os quais se encontram acuados pela ação delituosa cada vez mais presente em seu cotidiano, decorrência da ineficiência da estrutura de segurança pública. O Poder Judiciário não pode responder da mesma forma ao criminoso que comete um crime de tal natureza àquele que pratica crime menos grave para a sociedade, embora punido com igual rigor pelo legislador. Como visto, tratou-se de crime com gravidade concreta, tendo em conta que, atuando em concurso e com uma arma de fogo, o réu e o comparsa realizaram o roubo dos veículos, restando inegável a maior periculosidade e a incapacidade de reação por parte do funcionário do estacionamento. Por isso, entende-se que outro não pode ser o regime inicial de cumprimento da pena.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os

princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, CLAYTON VENANCIO DA CONCEIÇÃO, às penas de 09 (noive) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de elevada pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual concedida às fls. 151.

Com o trânsito em julgado da presente sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Observo que o laudo do IML do réu (fls. 125/126) não indica qualquer lesão e tampouco há qualquer menção sobre eventual violência praticada por parte da vítima ou dos policiais, razão pela qual desnecessária qualquer comunicação à Corregedoria da Polícia Militar sobre tal aspecto.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA